

1500875-73.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI  
Comarca: São Pedro  
Foro: Foro de São Pedro  
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Consta ainda que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Renato Bonfiglio, nº 163, Bela Vista, nesta cidade e Comarca, os imputados traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 88 [oitenta e oito] invólucros plásticos de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500875-73.2022.8.26.0599 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500875-73.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL MENDES MONTEIRO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos, em audiência.

FLÁVIO RODRIGUES LIMA e RAFAEL MENDES MONTEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo consta na denúncia, em data não especificada até 15 de junho de 2022, os acusados previamente ajustados e em unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Consta ainda que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Renato Bonfiglio, nº 163, Bela Vista, nesta cidade e Comarca, os imputados traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 88 [oitenta e oito] invólucros plásticos de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha [massa líquida de 88g]; 22 [vinte e dois] eppendorfs contendo cocaína [massa líquida de 4,4g]; e 349 [trezentos e quarenta e nove] eppendorfs contendo cocaína na forma solidificada, vulgarmente conhecida como crack [massa líquida de 34,9g], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os imputados foram citados e apresentaram resposta à acusação [fls. 193].

Recebida a denúncia em 15 de setembro de 2022.

Na audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, assim como foram interrogados os imputados ao final do ato.

As partes apresentaram memoriais, substitutos dos debates orais.

Vieram os autos conclusos.

É, do necessário, o relatório.

Fundamento e decido.

De início, vale frisar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito da contenda.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [Art. 35 da Lei 11.343/06]

Para a configuração do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 exige-se a demonstração mínima da existência de estabilidade e permanência entre os agentes, não bastando para a incidência da referida norma o concurso eventual e/ou ocasional de agentes.

Da prova oral amalha aos autos, notadamente dos relatos dos policiais que realizaram as operações ao combate ao tráfico e realizaram as prisões dos imputados, não é possível extrair que os inculpatos se associaram também em outras datas para praticar a chatinagem, tampouco que havia um o vínculo entre eles, minimamente estável, objetivando perpetrar atos antijurídicos previstos na legislação especial mencionada na inicial acustória.

Assim, tendo em vista que não houve a comprovação de que os inculpatos estavam associados em caráter estável ou permanente com o fim de praticar a mercancia, ônus da prova que competia à acusação [artigo 156 do CPP], a absolvição dos imputados, no ponto, é providência impositiva.

TRÁFICO [art. 33 da Lei 11.343/06]

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão [fls. 26/27], da fotografia [fls. 28], do laudo de constatação preliminar do entorpecente [fls. 30/33] e da prova pericial das folhas 222/225.

Quanto à autoria, de igual forma, emerge indubitosa da prova colacionada, recaindo certa sobre os inculpatos, firmada que está na sua prisão em flagrante, assim como na palavra coerente e convincente das testemunhas ouvidas durante a persecução penal. Senão vejamos.

O acusado FLÁVIO RODRIGUES LIMA, permaneceu em silêncio na fase inquisitorial. Em pretório, disse que, no dia dos fatos, estava trabalhando na lanchonete e Rafael aguardando do lado de fora, pois estava aguardando o seu lanche. Chegou um policial a pé e outros em uma viatura. Os armígeros disseram que se tratava de denúncia. Afirmou que sua lanchonete possui câmeras de segurança. Os policiais retiraram o cartão de memória das câmeras e destruíram. Perguntaram se poderiam revistar o local, quando autorizou. Os policiais perguntaram se possuíam drogas, quando disse que não. Foram levados até a Delegacia e, lá, retiraram uma sacola de drogas e passaram a decidir para quem iriam imputar os estupefacientes. Aduziu que o liquidificador era seu e as balanças também, utilizando tais equipamentos na sua lanchonete. O liquidificador estava na caixa e foi apresentado sujo na Delegacia. Não conhecia os armígeros antes dos fatos. Conhece rafael apenas de sua lanchonete, pois é seu cliente. Possui o comércio desde o ano passado. Os dois menores, conhecia apenas por serem seus clientes. Passou a residir no estado de São Paulo em 2018. Passou a morar em Piracicaba até 2019, quando mudou-se para São Pedro/SP. Passou a trabalhar como servente de pedreiro, economizando dinheiro que usou para montar seu estabelecimento.

O denunciado RAFAEL MENDES MONTEIRO, na etapa administrativa, permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que trabalhava como pintor. Asseui que foi até a lanchonete comprar um lanche, quando foi abordado. A polícia mandou ingressar na lanchonete. Encontraram drogas no interior da lanchonete e perguntaram de quem era, quando respondeu que não sabia. Asseui que os policiais disseram que, se Flávio não assumisse a propriedade dos estupefacientes, iram ser entorjados nos menores. Os policiais disseram que encontraram os estupefacientes próximo ao um sofá, mas não viu. No local dos fatos não viu as drogas. Primeiro formam no CDP de São Pedro/SP e, após, foram levados para Piracicaba/SP. Quando era menor, foi abordado pelos mesmos armígeros e foi apreendido com drogas. Conhecia Flávio apenas da lanchonete. Havia dois menores no local também. Flávio lhe disse que havia câmeras em seu estabelecimento. Apenas um dos policiais que lhe prendera foi o mesmo que

lhe abordou quando ainda era inimputável. Asseriu que foi agredido pelos policiais com enforcamento e socos em seu tórax. Não passou por exame com médico. Não foram levados para realizar exame de corpo de delito.

Entretanto, as versões exculpatórias dos inculpatados, não resistem quando confrontadas com o restante da globalidade probatória, a qual, aliás, é altamente inculpatória, segura para a prolação de édito condenatório. Senão vejamos.

As testemunhas Genivaldo Lopes de Souza e Rodolfo Aparecido Moraes de Oliveira, nas duas fases da ausculta, relataram que receberam uma denúncia, via COPOM, de que o acusado Flávio estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes em um bar. Ao chegarem no local indicado, sendo este uma lanchonete, visualizaram uma pessoa identificada como Rafael passando algo para outra pessoa desconhecida, através de um alambrado. Declararam que o desconhecido, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se, correndo para dentro da comunidade, não sendo possível a abordagem. Desembarcaram da viatura e abordaram o acusado Rafael na entrada da lanchonete. Realizaram revista pessoal, encontrando na posse do acusado uma quantia de 56 [cinquenta e seis] "pinos" de crack e o valor de R\$ 24,00 [vinte e quatro reais] em espécie. No interior do comércio havia outras pessoas, e uma delas estava sentada em um sofá, identificado como Flávio. Relataram que o increpado Flávio estava com um pote com 67 [sessenta e sete] micro pinos de crack, semelhantes ao encontrado com o imputado Rafael, 88 [oitenta e oito] porções de maconha, 01 [um] celular samsung e o importe de R\$60,00 [sessenta reais] em notas diversas. No palco dos acontecimentos, havia dois adolescentes identificados por Carlos e Patrik. Este último, ao avistar a presença dos agentes, correu para os fundos do fundo de comércio. Realizaram a revista pessoal nos adolescentes, encontrando apenas dois aparelhos celulares em sua posse. Relataram que realizaram buscas, encontrando na cozinha uma grande quantidade de drogas em uma sacola branca, contendo 226 [duzentos e vinte e seis] micro pinos de crack, e 22 [vinte e dois] micro pinos de cocaína, um pote o valor de R\$ 57,95 [cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos] em moeda, bem como um aparelho celular motorola. Disseram que, na cozinha, também encontraram um liquidificador com resquícios de entorpecentes e duas balanças de precisão. Declararam que apuraram ser o acusado Flávio o proprietário da lanchonete. Informaram que este confessou informalmente que a droga que estava ao seu lado era de sua propriedade. Asseriram que os demais presentes se mantiveram em silêncio. Em pretório, disseram que visualizaram pelo alambrado que um terceiro pegou algo que Rafael alcançou pelo alambrado. Havia dois menores no local. Ao lado de Flávio foram encontradas drogas e dinheiro. Com Rafael foram encontradas drogas também e dinheiro. Com os dois menores que estavam no local nada de ilícito foi encontrado, apenas dois celulares. No estabelecimento também encontraram drogas, dinheiro, balanças de precisão, outros celulares e um liquidificador com substância aparentando ser cocaína. Flávio confessou que as drogas que com ele foram encontradas lhe pertenciam. Em um pote de sorvete ao lado de Flávio estavam parte dos estupefacientes. Já haviam recebido informações anteriores a respeito de ambos, inclusive havendo a abordagem deles em outras oportunidades, mas nada de ilícito com eles foi encontrado. A delação anônima apontava que Flávio era o dono do estabelecimento onde encontraram os estupefacientes. Destacaram que Rafael era conhecido nos meios policiais. Flávio sempre era visto no local conhecido como ponto de venda de drogas.

Ainda no ponto, calha destacar, que o fato de ser agente de segurança pública não retira a credibilidade das informações trazidas pela testemunha. A condição funcional da testemunha não é causa de impedimento para ser ouvida como tal.

Ademais, não há qualquer indício de que tenham motivos para imputar graciosamente os fatos aos réus. Portanto, seus relatos são aptos à construção do convencimento e encontram-se em consonância com o restante das provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido. E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROVA. Depoimento policial Valor Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de

sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido neste aspecto" (TJSP Apelação Criminal nº 993.08.043553-7 São Paulo 16ª Câmara de Direito Criminal Relator Newton Neves 09.09.2008 v.u.).

Na mesma senda, C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

IV - Afastar a condenação com base na nulidade da instrução, em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feitas pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

V - Repiso, que seria necessário aprofundado reexame do conjunto fático probatório a análise da tese de que o paciente faria jus a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, constante do do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo inviável sua análise em razão dos limites impostos à via mandamental.

VI - Consoante ficou assentado na decisão agravada, o quantum de pena aplicado (6 anos de reclusão), o regime poderia, em princípio, ser o semiaberto. Todavia, não se pode olvidar a existência de circunstâncias desfavoráveis que foram consideradas na dosimetria da pena, na terceira fase, para afastar a causa especial de redução de pena. Assim, inviável a fixação do regime intermediário (semiaberto) unicamente em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006.

VII - Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda encontra-se estabelecida acima do patamar prevista para o deferimento da benesse (6 anos de reclusão), nos termos do art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (original sem grifo)

Nessa esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, ainda que os réus tenham negado a prática do crime a eles imputado, suas versões encontram-se completamente isoladas das demais provas amealhadas aos autos, especialmente as produzidas em audiência.

Os elementos de convencimento corporificados aos autos demonstram que o palco dos acontecimentos é conhecido por ser local de venda de drogas, a ponto de haver

denúncias apócrifas apontando tal situação. Também verifica-se do conjunto probatório que o inculcado Flávio era o proprietário do estabelecimento no qual foram encontrados os estupefacientes, bem como que fora seu nome indicado na delação anônima, como pessoa que realizava chatinagem no local, o que foi por ele confessado extrajudicialmente aos armígeros que realizaram sua prisão. Ainda, extrai-se das provas jungidas aos autos que o increpado Rafael, no mesmo local, fora flagrado entregando algo a um terceiro desconhecido, que evadiu-se do local, bem como que, abordado, com ele foram encontradas drogas idênticas as encontradas com o correu Flávio.

Mas não é só. A imagem da folha 28, bem como o restante da prova documental e pericial produzidas no processo corroboram a prova oral colhida durante as duas fases da ausculta. Infere-se da prova documental e pericial que no estabelecimento comercial do increpado Flávio, onde, reitera-se, também estava o acusado Rafael, foram encontradas duas balanças de precisão, um liquidificador com drogas dentro, dinheiro em espécie e em valores trocados e celulares. E se percebe que os estupefacientes apreendidos apresentam características idênticas de cor e embalagem, separados apenas por cores diversas conforme sua natureza. Ou seja, tudo indica que toda droga apreendida adveio do mesmo local. Ainda a prova pericial de folhas 155/157 aponta que no liquidificador encontrado no estabelecimento comercial do inculcado fora encontrado resquícios de estupefacientes.

E, enquanto o caderno probatório mostrou-se altamente incriminatório, apto ao édito condenatório, as versões de defesa pessoa dos inculcados não vieram embasadas em qualquer lastro probatório [artigo 156 do CPP]. Aliás, poderiam os denunciados ter comprovado suas teses exculpatórias por meio de prova oral. Por exemplo, os depoimentos dos menores que estavam no palco dos acontecimentos no momento da ação policial poderia ser meio para instaurar minimamente um juízo de dúvida, o que não aconteceu.

Ante todo o exposto, à vista dos elementos probatórios carreados aos autos, confrontados com os interrogatórios dos réus, só resta reconhecer a responsabilidade deles pelo delito de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06], crime, aliás, equiparado a hediondo [artigo 2º da Lei nº 8.072/90]. Passo ao exame das teses defensivas ainda não enfrentadas de cada um dos imputados. Como tese de defesa pessoal, alegam os increpados a ocorrência de flagrante forjado.

A tese também não merece acolhida.

A alegação de flagrante forjado é a mais comum em processos criminais, versão natural de quem pode se valer de, praticamente, todos os meios na tentativa de escusar-se da responsabilidade penal resultante de suas ações.

Entretanto, mesmo no processo penal, onde vigoram princípios como o do *in dubio pro reo*, exige-se a comprovação mínima das teses ventiladas pela defesa e pelos réus, pois há também uma divisão do ônus da prova [artigo 156 do CPP].

E na hipótese vertente, a tese de flagrante simulado não veio respaldada por qualquer tipo de prova produzida pela Defesa, seja oral ou testemunhal, que, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 156 do CPP.

Ademais, não crível acreditar que agentes de segurança pública andem pelas ruas na posse de entorpecentes para imputar graciosamente crimes a cidadãos.

Outro fator que merece destaque no ponto é o fato de que a ação policial foi presenciada por duas outras pessoas – C.K.E.A.S. e P.H.F. – que não foram arroladas como testemunha pela Defesa e, na fase inquisitorial, nada referiram acerca do suposto flagrante simulado ou que pudesse conduzir a alguma suspeita de tal conduta dos armígeros [fls. 08/09].

Também vem de encontro à alegação dos acusados o fato de no liquidificador que, segundo o imputado Flávio lhe pertencia, era novo e estava embalado ainda, foram encontrados vestígios de drogas [fls. 155/157].

Outro ponto que coloca em descrédito os relatos dos implicados fora a alegada violência policial relatada pelo acusado Rafael e que não teria sido examinado por profissional da saúde após sua prisão, a qual foi negada por ele na fase administrativa [fls. 12/13], nada há a respeito na decisão proferida em audiência de custódia por outro Magistrado [fls. 78/79] e é totalmente desterrada pela prova

documental de folha 75 e pericial de folha 154.

Não há falar, portanto, em flagrante forjado.

Ainda em relação à tese de defesa pessoal dos acusados de flagrante forjado, tal conduta demonstra sua personalidade propensa ao cometimento de ilícitos, pois compareceram em Juízo e, muito além do direito ao silêncio, mentiram para a Justiça, inclusive imputando aos policiais a prática de falsa comunicação de crime e, no caso do imputado Rafael, ainda, outros crimes, apenas para tentar se esgueirar das consequências de seus atos.

É certo que "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo"

Diante desse quadro, na primeira fase do processo dosimétrico, as incoativas impostas aos inculcados serão elevadas, pois demonstraram com suas condutas que possuem personalidade propensa ao cometimento de ilícitos, sequer contendo seu ímpeto na Casa da Justiça.

Cabe remarcar, ainda, que a condenação pelo tráfico, tal como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.

Como já exposto, "é desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12, da Lei nº 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos" (TJSP, Rev nº 261.898-3/2, rel. Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel. Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639, 594/393, "apud" Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3.132).

Na realidade, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico. Este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" [VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151, grifei]. O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização [STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer].

Em relação ao fato de o inculcado Fábio possuir trabalho lícito, em nada altera o deslinde do feito, pois o tráfico não exige dedicação em tempo integral ou destinação exclusiva do local onde é cometido.

Inviável a aplicação da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se da certidão da folha 65 dos autos que o imputado Rafael, no dia 11/06/2021, cometeu o mesmo ilícito, enquanto ainda inimputável, razão pela qual lhe foi aplicada medida de internação [fls. 128/139 do processo nº 1500914-07.2021.8.26.0599]. A restrição de sua liberdade em virtude de tal processo perdurou até o dia 19/01/2022, quando foi entregue ao seu responsável legal [processo nº 0007652-44.2021.8.26.0451, fl. 82]. Menos de 6 meses após ter sido posto em liberdade - 15/06/2022 - voltou a perpetrar o mesmo ilícito.

Destarte, tenho por bem caracterizado que o imputado se dedica a atividades criminosas.

A respeito, C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL E DE AÇÕES PENAS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO

PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS PRESUMIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
  2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.
  3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
  4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).
  5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
  4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas.
  5. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
  6. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (REsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).
  7. A presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, no registro de atos infracionais e na quantidade de droga apreendida não se harmoniza com a orientação predominante do STF.
  8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.934.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) [Original sem grifo]
- Mas não é só.
- Agora tratando também da situação do imputado Flávio, o local onde estavam realizando o comércio espúrio, conforme se observa dos relatos das testemunhas presenciais dos fatos, era conhecido como local de venda de drogas, a ponto de populares, certamente cansados de tal situação, delatarem anonimamente tais acontecimentos, o que ensejou a ação policial. A delação anônima apontava o nome de Flávio como sendo o autor do delito. As prova testemunhal também aponta que ambos os imputados haviam sido delatados em outras oportunidades.
- Todo esse contexto demonstra que se dedicavam ao comércio espúrio com assiduidade. Aliado a esse quadro, a excessiva quantidade, variedade e naturezas diversas dos entorpecentes apreendidos com os inculpatados, a forma como estavam acondicionados, são circunstâncias que impedem a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que evidenciam que os réus não praticam essa espécie de crime ocasionalmente, mas, ao contrário, estão envolvidos com atividades criminosas, circunstância que, inclusive, também se extrai do restante do caderno probatório, o qual indica que os acusados estavam vendendo drogas para outras pessoas, flagrado um deles em tal atitude no palco dos acontecimentos.

Sobre o tema, vale referir trecho do decidido pelo C. STJ:

(...) Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado, bem como a sua natureza, constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à mingua do preenchimento dos requisitos legais (...) (REsp n. 1.344.604/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 19.12.2013).

As circunstâncias da prisão dos imputados, bem como a vida anteacta do réu Rafael, denotam que não eram eles "causais mercadores" de estupefacientes. De certo que a neófito não seria confiada tal quantidade e variedade de entorpecentes, estes que, aliás, para serem comercializados, também dependeriam de certa dedicação e empenho, pelos acusados ou por outros asseclas ignotos, atingindo considerável número de usuários. Também o inculcado Rafael não teria voltado a delinquir em tão curto período de tempo após ter sido posto em liberdade.

Visa a Lei, não se pode ignorar, dentro outros objetivos, atingir com a benesse do § 4º do artigo 33, o chatin não eventual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder apresenta-se capaz de atingir pequeno número de usuários, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas.

Assim, as peculiaridades do caso em liça, suso mencionadas, não autorizam a aplicação da minorante, sob pena, inclusive, de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo legal.

Consigno, ainda no ponto, que a quantidade de droga apreendida com os inculcados, mesmo sendo utilizada para afastar ao privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, poderá ser sopesada negativamente na primeira fase do processo dosimétrico, sem que isso consista em bis in idem, conforme se infere da jurisprudência do C. STF, in verbis:

(...) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no AREn. 666.334(Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" [ARE 666.334/RG, Rel. Min.: Gilmar Mendes; DJ de 6/5/2014]" [HC nº 370.057 RO; Rel. Min. Joel Ilanpaciornik; j. 01.12.16].

Destarte, reitera-se, a prova é certa, segura e aponta que os réus praticaram, em comparsaria, os fatos antijurídicos descritos na inicial acusatória.

Malgrado tenham sido flagrados menores no palco dos acontecimentos, o local também era um comércio de alimentos, o que pode justificar em alguma medida lá a presença dos dois menores. E não há nos autos elementos suficientemente robustos que indiquem que o tráfico realizado pelos inculcados envolvia ou visava menores de 18 anos.

Assim, não reconheço a incidência do inciso VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/06 ao caso em liça.

O inculcado Rafael contava com pouco mais de 18 anos de idade ao tempo dos fatos [fl. 47]. Logo, aplicável a ele a atenuante do artigo 65, I, do CP.

Diante de todo o exposto, a absolvição é meta impossível de ser alcançada quanto ao delito em questão, inclusive por não haver nos autos qualquer causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, sendo totalmente imputável.

Passo a dosar as penas

ACUSADO FLÁVIO

Crime do art. 33, caput, Lei 11.343/06.

1ª fase - circunstâncias judiciais [artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº



11.343/06]

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta não excede o ordinário.

O acusado não registra antecedentes.

A conduta social do inculcado não foi desabonada.

O inculcado demonstra personalidade propensa ao cometimento do ilícito, pois, nos termos da fundamentação supra, nem mesmo o fato de estar na Casa da Justiça impediu que seguisse com seu ímpeto de cometer atos ilícitos.

Os motivos do crime são inerentes à espécie, lucro fácil às expensas da saúde pública.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, tendo em vista a quantidade de droga [293 porções de crack, 88 porções de maconha e 22 porções de cocaína], de natureza variada, encontrada em poder do acusado e as características de duas delas – crack e cocaína –, de elevado poder viciante e destrutivo. No ponto, consigno que a natureza e a quantidade dos entorpecentes devem ser valorados nesta fase do processo dosimétrico por expressa previsão legal [artigo 42 da Lei nº 11.343/06]. Além disso, desconsiderar a natureza e quantidade dos entorpecentes, quando destoem do que ordinariamente se verifica em casos análogos, é negar vigência à norma mencionada supra, bem como aos princípios constitucionais da individualização da pena e da isonomia, pois se estaria dispensando tratamento idêntico aos que comercializam estupefacientes de menor potencial lesivo à saúde pública e se encontram na posse de pequena quantidade de drogas, aos que vendem entorpecentes de elevado poder viciante e destrutivo e foram flagrados na propriedade de grande quantidade de drogas. Em última análise, a quantidade e a natureza das drogas deve ser sopesada neste vetor, porquanto eleva em muito o desvalor da ação perpetrada pelo inculcado, obedecendo-se, assim, expressa disposição de lei. Mas não é só. Também foram encontrados objetos destinados ao preparo das drogas, alguns deles ainda com resquícios de estupefacientes [artigo 34 da Lei nº 11.343/06]. Por mais que tais fatos tenham sido absorvidos pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – princípio da consunção –, elevam sobremaneira o desvalor da ação perpetrada pelo inculcado. Ainda, o delito foi perpetrado em comparsaria entre os réus, o que transcende as exigências do tipo penal para sua configuração e a gravidade da conduta, pois em mais de um agente mais usuários podem ser atingidos e menos tempo e as chances de sucesso na empreitada criminosa também são elevadas.

As consequências do fato não destoaram das normais ao ilícito.

Não há comportamento da vítima a ser considerado, pois se trata de crime que atinge toda a coletividade.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 08 [oito] anos de reclusão e 800 [oitocentos] dias-multa, reprimendas que vão definitivadas em virtude de incidir, ao caso em testilha circunstâncias legais.

Quanto à razão unitária de cada dia-multa, tendo em vista a condição econômica do implicado, fixo-a em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, em observância ao que preceitua o artigo 33 do CP e o artigo 387, § 2º, do CPP, considerando as operadoras do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, analisadas na primeira fase da individualização da pena, especialmente as vetoriais personalidade e circunstâncias do crime, mostrando-se o regime fixado o mais adequado à necessária reprovação e prevenção do ilícito penal, que é grave, comparado a hediondo e que coloca em risco a ordem pública e a paz social.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF – HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo leciona Cezar Roberto Bittencourt, “quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33,

§ 3º, do CP)" [Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva 2008, p. 450].

Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [cf. HC. n. 279.272/SP, Rel.Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012]

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito [artigo 44 do CP], tampouco de suspensão da execução da pena privativa de liberdade [artigo 77 do CP].

DENUNCIADO RAFAEL

Crime do art. 33, caput, Lei 11.343/06.

1ª fase – circunstâncias judiciais [artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06]

A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta não excede o ordinário.

O acusado não registra antecedentes.

A conduta social do inculcado não foi desabonada.

O inculcado demonstra personalidade propensa ao cometimento do ilícito, pois, nos termos da fundamentação supra, nem mesmo o fato de estar na Casa da Justiça impediu que seguisse com seu ímpeto de cometer atos ilícitos.

Os motivos do crime são inerentes à espécie, lucro fácil às despesas da saúde pública.

As circunstâncias do delito desbordaram da previsão típica, tendo em vista a natureza das drogas com ele encontradas – crack – de elevado poder viciante e destrutivo. No ponto, consigno que a natureza e a quantidade dos entorpecentes devem ser valorados nesta fase do processo dosimétrico por expressa previsão legal [artigo 42 da Lei nº 11.343/06]. Além disso, desconsiderar a natureza e quantidade dos entorpecentes, quando destoem do que ordinariamente se verifica em casos análogos, é negar vigência à norma mencionada supra, bem como aos princípios constitucionais da individualização da pena e da isonomia, pois se estaria dispensando tratamento idêntico aos que comercializam estupefacientes de menor potencial lesivo à saúde pública e se encontram na posse de pequena quantidade de drogas, aos que vendem entorpecentes de elevado poder viciante e destrutivo e foram flagrados na propriedade de grande quantidade de drogas. Em última análise, a quantidade e a natureza das drogas deve ser sopesada neste vetor, porquanto eleva em muito o desvalor da ação perpetrada pelo inculcado, obedecendo-se, assim, expressa disposição de lei. Mas não é só. O delito foi perpetrado em comparsaria entre os réus, o que transcende as exigências do tipo penal para sua configuração e a gravidade da conduta, pois em mais de um agente mais usuários podem ser atingidos e menos tempo e as chances de sucesso na empreitada criminosa também são elevadas. As consequências do fato não destoaram das normais ao ilícito.

Não há comportamento da vítima a ser considerado, pois se trata de crime que atinge toda a coletividade.

Pelo conjunto desses vetores, fixo a pena-base em 06 [seis] anos de reclusão e 600 [seiscentos] dias-multa.

2ª e 3ª fases – circunstâncias legais

Ao tempo dos fatos, o imputado contava com pouco mais de 18 anos de idade, assim, por aplicação da atenuante do artigo 65, I, do CP, reduzo as incoativas em 1 [um] ano de reclusão e 100 [cem] dias-multa, restando as sanções definitivadas em 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias multa.

Quanto à razão unitária de cada dia-multa, tendo em vista a condição econômica do implicado, fixo-a em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, em observância ao que preceitua o artigo 33 do CP e o artigo 387, § 2º, do CPP, considerando as operadoras do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, analisadas na

primeira fase da individualização da pena, especialmente as vetoriais personalidade e circunstâncias do crime, mostrando-se o regime fixado o mais adequado à necessária reprovação e prevenção do ilícito penal, que é grave, comparado a hediondo e que coloca em risco a ordem pública e a paz social.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF – HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo leciona Cezar Roberto Bittencourt, “quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)” [Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva 2008, p. 450].

Ademais, os dados fáticos da conduta delitiva, quando demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [cf. HC. n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012]

Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito [artigo 44 do CP], tampouco de suspensão da execução da pena privativa de liberdade [artigo 77 do CP].

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial acusatória, razão pela qual:

A) ABSOLVO os réus das imputações de terem cometido o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal;

B) CONDENO FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA à pena de prisão, pelo período de 08 [oito] anos, em regime inicial fechado, e 800 [oitocentos] dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 2º da Lei nº 8.072/90.

C) CONDENO RAFAEL MENDES MONTEIRO à pena de prisão, pelo período de 5 [cinco] anos, em regime inicial fechado, e 500 [quinhentos] dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 2º da Lei nº 8.072/90.

Denego o direito de os réus aguardarem ao trânsito em julgado da decisão em liberdade, porque persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa. Além disso, a conduta perpetrada pelos inculpatos é grave, pois praticaram a venda de entorpecentes de elevado poder viciante e destrutivo, de natureza variada e em comparsaria, colocando em risco, assim, a paz social, a segurança e a ordem pública, justificando a manutenção da segregação cautelar. Ainda, em relação ao imputado Fábio a elevada quantidade de estupefacientes com ele encontrados, bem como os objetos destinados ao seu preparo também apontam a gravidade de sua conduta. E o sentenciado Rafael há poucos meses estava em liberdade, pois cumprira pena de internação pelo mesmo ilícito, voltando a delinquir em curto interstício de tempo, mostrando que, em liberdade, tende a seguir cometendo ilícitos. Destarte, vai mantida a segregação antecipada dos acusados para que a ordem pública siga mantida. Custas pelos acusados.

Expeça-se o PEC provisório, adequando-se ao regime fixado.

Recomendo os condenados à unidade prisional em que se encontram.

Se o caso, oportunamente, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Após o trânsito em julgado da sentença, se mantida a condenação, procedam-se às anotações de estilo, com o lançamento do nome do réu no rol de culpados, formação do PEC definitivo e posterior remessa à VEC, oficiando-se ao TRE.

Destruam-se as substâncias entorpecentes, nos termos do artigo 52-A e artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado desta decisão, declaro perdidos os valores apreendidos com o imputado, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Carta da República. P.R.I.  
São Pedro, 02 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA